

1502733-88.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... seria o responsável pela função de "olheiro" do tráfico de drogas e FERNANDO LIMA FARIAS, informalmente, declarou que era ele o responsável pela venda das substâncias entorpecentes para usuários de drogas.

Ouvido em juízo, o policial Eduardo Simões de Araújo acrescentou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas. No dia dos fatos, dirigiram-se ao local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502733-88.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502733-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030605/2022 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 22786557 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 380/22/373 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 2030605 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MICHAEL XAVIER e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

FERNANDO LIMA FARIAS e MICHAEL XAVIER foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 02 de fevereiro de 2022, à tarde, na Avenida Nova Arcádia, altura do nº 803, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de designios, traziam consigo, para fins de traficância, 101,3g (cento e um gramas e três decigramas) de "TETRAHIDROCANNABINOL", vulgarmente conhecido como maconha, divididos em 30 (trinta) porções; 26g (vinte e seis gramas) de cocaína, divididos em 67 (sessenta e sete) porções; e 5,4g (cinco gramas e quatro decigramas) de cocaína na forma de crack, divididos em 32 (trinta e duas) porções. Trata-se de

substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fls. 47/50) e, posteriormente, à perícia químico-toxicológica (fls. 180/182).

A denúncia foi recebida (fls. 137/138).

O réu FERNANDO constituiu advogado (fls. 100) e apresentou defesa prévia (fls. 146/148), após o que o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 151). O réu MICHAEL constituiu advogado (fls. 98) e apresentou resposta à acusação (fls. 154/155), após o que o recebimento também foi ratificado (fls. 158/160).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas, e os acusados foram interrogados ao final.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, vez que evidentes a autoria e a materialidade.

A Defesa de FERNANDO, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, requereu a aplicação do disposto no § 4º, do artigo 33, com a redução da pena aplicada, na proporção de 1/6 (um sexto) à 2/3 (dois terços), o estabelecimento do regime mais brando, conversão da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito e o apelo em liberdade.

Por seu turno, a defesa de MICHAEL requereu a absolvição com base nos artigos 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da lei 11.343/06, ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, em seu patamar máximo, a aplicação da redutora de um terço, prevista no parágrafo primeiro do art. 29 do Código Penal, diante da participação de menor importância. Por fim, pleiteou que a privativa de liberdade fosse convertida em pena em restritiva de direitos, bem como o apelo em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é parcialmente procedente.

Inferre-se do conjunto probatório harmônico que os acusados, no dia 02 de fevereiro de 2022, à tarde, na Avenida Nova Arcádia, altura do nº 803, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de traficância, 101,3g (cento e um gramas e três decigramas) de "TETRAHIDROCANNABINOL", vulgarmente conhecido como maconha, divididos em 30 (trinta) porções; 26g (vinte e seis gramas) de cocaína, divididos em 67 (sessenta e sete) porções; e 5,4g (cinco gramas e quatro decigramas) de cocaína na forma de crack, divididos em 32 (trinta e duas) porções. Trata-se de substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais civis faziam operação de combate ao tráfico de drogas na região e avistaram os denunciados em atitude suspeita, razão pela qual permaneceram em campana. Após breve período, verificaram que FERNANDO era eventualmente abordado por terceiros, ao passo que MICHAEL ficava um pouco mais distante, observando a movimentação e comunicando-se com FERNANDO por meio de olhares, gestos e sinais. Fizeram isso durante certo período de tempo, até que, num momento em que começou a chover, os denunciados se reuniram e passaram a conversar, oportunidade em que os policiais realizaram a abordagem de ambos. Em regular

procedimento de revista, foi encontrada em poder de FERNANDO uma pochete, dentro da qual estava o farto material entorpecente acima mencionado, além da quantia de R\$ 41,00 (quarenta e um reais). Indagados, os denunciados admitiram aos policiais que estavam no local para realizar o tráfico de drogas, sendo certo que MICHAEL exercia a função de "olheiro" e FERNANDO era o responsável pelas vendas das drogas.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo de constatação (fls. 47/50), laudo de perícia químico-toxicológica (fls. 180/182), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 07/08), os acusados permaneceram em silêncio.

Ouvidos em juízo, os réus confirmaram que não conheciam os policiais de data anterior.

FERNANDO LIMA FARIAS disse ter 43 anos. Alegou que conhecia MICHAEL em razão da sua relação de amizade. Negou que exercesse o tráfico de drogas. Disse que foi ao local somente para comprar drogas. Não foi abordado com drogas.

MICHAEL XAVIER disse ter 30 anos. Conhecia FERNANDO. Negou que exercesse a função de olheiro. Foi ao local somente para comprar drogas. Não viu a apreensão das drogas com FERNANDO. Disse que é usuário de drogas desde os 17 anos de idade.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pelos acusados restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

Os policiais civis Eduardo Simões de Araújo e Israel Simões de Araújo narraram de forma segura e uníssona, em ambas as fases da persecução penal, a diligência realizada.

Na delegacia (fls. 22/23), disseram que, em diligências direcionadas ao combate da prática do tráfico de entorpecentes, diligenciaram ao local tido como dos fatos, onde puderam observar, após breve período de campana, a presença de dois indivíduos em atitude suspeita. Ambos estavam em pontos distintos do local em que observação era feita, porém ambos estavam dentro do mesmo campo de visão dos policiais. Ao iniciar uma chuva pelo local, os dois indivíduos se aproximaram um do outro e iniciaram uma conversa. Contaram que, nesse momento, foi procedida a abordagem dos indivíduos e os mesmos se apresentaram como MICHAEL XAVIER e FERNANDO LIMA FARIAS, sendo que FERNANDO interagiu com as pessoas que lhe abordavam, enquanto MICHAEL permaneceu distante apenas observando a movimentação ao redor e ambos faziam constante contato visual e de sinais. Confirmaram que, após busca pessoal, foi encontrada na posse de FERNANDO LIMA FARIAS, mais especificamente em sua cintura, uma pequena bolsa, conhecida popularmente como pochete, e que dentro do referido objeto estavam acondicionados os entorpecentes relacionados neste registro embalados em pequenas porções destinadas a venda para usuários de substâncias entorpecentes, bem como a quantia em dinheiro aqui relacionada. Indagado, informalmente, MICHAEL XAVIER declinou que seria o responsável pela função de "olheiro" do tráfico de drogas e FERNANDO LIMA FARIAS, informalmente, declarou que era ele o responsável pela venda das substâncias entorpecentes para usuários de drogas.

Ouvido em juízo, o policial Eduardo Simões de Araújo acrescentou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas. No dia dos fatos, dirigiram-se ao local descaracterizados. No local, passando-se por um morador, ficou observando a movimentação e visualizaram os dois acusados a uma distância, entre eles, de cerca de 6 metros. Foi possível visualizar duas pessoas que se aproximaram dos réus. A

primeira pessoa se aproximou do réu MICHAEL e este indicou FERNANDO, para onde a pessoa se dirigiu e pegou algo das mãos deste; a segunda pessoa se aproximou e conversou com os dois acusados. Contou que, após iniciar uma chuva, os dois decidiram se proteger da chuva, momento em que conseguiram abordar ambos. Com o réu FERNANDO encontraram uma pochete com drogas e dinheiro em seu interior. Não conhecia os acusados. O MICHAEL era o olheiro e indicava aos usuários quem vendia as drogas. O réu FERNANDO era quem vendia as drogas. O réu FERNANDO admitiu a traficância, enquanto MICHAEL negou que desempenhasse o tráfico de drogas. A campana durou cerca de 8 minutos, e os acusados demonstravam tensão, observando o local. MICHAEL não fez nenhuma transação e nenhuma droga ou dinheiro foram encontrados com ele. Incursões policiais são realizadas constantemente no local da apreensão as drogas, asseverou o policial.

Em juízo, o policial Israel Simões de Araújo acrescentou que o local é conhecido já em razão de outras ocorrências. No dia, decidiram ir até ao local de viatura descaracterizada para verificar possível evidência de traficância. No local, uma praça, ficaram em campana de 5 a 10 minutos e perceberam pessoas se aproximando e trocando objetos com uma pessoa. Os réus estavam a uma distância de 5 metros entre si. Ocorre que, após iniciar uma chuva, os dois se aproximaram e ficaram embaixo de uma cobertura. Abordaram os dois indivíduos e, com um deles, FERNANDO, encontrou uma pochete com as drogas em seu interior. O MICHAEL desempenhava a conduta de olheiro, verbalizando com os possíveis clientes e indicando quem vendia as drogas. O réu FERNANDO era o responsável pela venda das drogas. Na quadra da praça, existiam outras pessoas praticando esporte, mas não estavam próximas aos réus. Não conheciam os réus. O réu FERNANDO admitiu a traficância, enquanto o réu MICHAEL negou a função de olheiro. A comunicação entre os dois acusados durante a ação era verbal, mas não conseguiu ouvir o que falavam. A pochete era na cor preta e de tamanho pequeno. O policial Eduardo foi o responsável pela detenção do réu MICHAEL.

Impõe-se ressaltar que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: "(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)" - (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

A coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de tráfico de entorpecentes pelos acusados.

Com efeito, os policiais ouvidos em juízo, prestaram relatos seguros e uníssonos, confirmando que apreenderam, na posse do réu FERNANDO, uma pochete com os entorpecentes, além de dinheiro, corroborando os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva. Ainda confirmaram que, em campana precedida da abordagem, visualizaram o réu MICHAEL em típica atitude de "olheiro".

Segundo os relatos dos policiais, em ambas as fases da persecução penal, MICHAEL permaneceu no local, conhecido pela venda de entorpecentes, por todo o período de campana, cerca de 10 minutos, verbalizando com pretensos "clientes" e indicando o

corrêu FERNANDO como sendo aquele que realizava a venda das drogas, vigiando, assim, o ambiente para avisar ao seu comparsa eventual aproximação policial. Confirmaram, inclusive, que ambos constantemente olhavam para o lado, apresentando tensão, e verbalizavam entre si, circunstâncias que comprovam que MICHAEL também concorria para a prática do tráfico de drogas. Em poder de FERNANDO apreenderam as drogas e quantia em dinheiro.

Ademais, não seria crível que MICHAEL estivesse no local apenas para a compra de entorpecentes, uma vez que nenhuma quantia em dinheiro foi apreendida em seu poder, e ainda por ter permanecido no local durante todo o tempo da campana policial, interagindo com o corrêu FERNANDO.

Cumprer ressaltar que, segundo afirmaram, os policiais sequer conheciam os réus e interesse algum teriam em prejudicá-los, imputando-lhes falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

Sendo assim, tem-se que a versão apresentada pelos acusados, no sentido de que apenas estariam no local para comprar entorpecentes restou absolutamente dissociada da prova oral colhida, razão pela qual afasta-se qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Não há que se falar em atipicidade da conduta do acusado MICHAEL, tampouco em desclassificação da capitulação jurídica nos termos do artigo 37, da Lei de Drogas, muito menos em participação de menor importância.. Isto porque, resta claro que aquele que exerce a atividade de "olheiro" do tráfico de drogas pratica o crime tipificado no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, uma vez que sua função é a de garantir a realização de qualquer das condutas ali descritas e, assim fazendo, concorre para que qualquer uma delas se concretize, em nítida coautoria.

Sobre o tema, assim leciona Guilherme Souza Nucci:

"... o intuito do legislador, ao adotar no tipo penal do artigo 37, da Lei nº 11.343/06, a teoria pluralista do concurso de agentes não foi a de alcançar aqueles que exercem funções habituais no tráfico, como o 'olheiro', pois este é coautor da conduta descrita no artigo 33, mas sim aqueles que normalmente não integram a associação criminosa, em suas diversas funções hierárquicas, mas acabam colaborando com informações privilegiadas e estratégicas para o exercício da traficância" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Ed. Forense, 8ª ed., pág. 367).

Outrossim, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando não somente a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (101,3g de "TETRAHIDROCANNABINOL", vulgarmente conhecido como maconha, divididos em 30 (trinta) porções; 26g de cocaína, divididos em 67 (sessenta e sete) porções; e 5,4g de cocaína na forma de crack, divididos em 32 porções), apreensão de quantia em dinheiro, assim como a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico. Nessas mesmas circunstâncias, sequer seria possível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, essencialmente por essas mesmas características de variedade e forma de acondicionamento dos tóxicos encontrados.

Cumprer ressaltar que, mesmo que os acusados sejam usuários de entorpecentes, tal situação, de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se dedicassem à comercialização de substâncias ilícitas, sendo, portanto, a análise das circunstâncias fáticas do caso determinante para aferição da real destinação das drogas.

A propósito do tema, tem julgado este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários,

frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (AP.n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, 9.ªCâm. Crim., j. em 31.03.2016).

Outrossim, ressalte-se que os documentos juntados às fls. 186/187 pela Defesa de MICHAEL em nada afastam o valor dos depoimentos aqui prestados pelos policiais que participaram da prisão dos acusados, vez que se referem a fatos alheios aos aqui tratados. Frise-se, também, que nenhuma prova foi produzida para que pudesse evidenciar, no caso em tela, eventual interesse dos policiais em falsamente incriminar os acusados, ônus que cabia à defesa, ex vi do artigo 156 "caput" do Código de Processo Penal.

Colaciona-se, na oportunidade, importante trecho do julgado juntado pela defesa de MICHAEL, demonstrando que, no processo mencionado, não foi produzida prova no sentido de que os agentes estatais dolosamente tenham incriminado injustamente alguém.

"E, na hipótese em debate, convém repisar, prestaram os policiais depoimentos contendo relevantes divergências na Delegacia e perante o N. Juízo a quo, mostrando-se possível, assim, tenham confundido os presentes fatos com outra ocorrência, o que deve ser resolvido em favor do réu".

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, as penas-base devem ser fixadas no patamar mínimo previstos para a espécie, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para ambos acusados.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, restam as penas provisórias dos réus em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ao depois, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, para ambos acusados, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, primário e de bons antecedentes (fls. 29/31), deve ser aplicada, ainda que de ofício.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: "Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de

rigor se considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento. Diante de tais ponderações e das constatações das provas produzidas, reduzo a pena de ambos os acusados em 2/3 (dois terços), atendendo-se aos critérios de proporcionalidade que decorrem da própria norma que estipula um parâmetro dentro do qual a redução deve ser realizada.

Como consequência, as penas restam definidas em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, atualizado.

Por conseguinte, considerando as particularidades do caso vertente, substituo as penas privativas de liberdade de ambos acusados por duas restritivas de direitos, a serem definidas em fase de Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena para os réus será o aberto.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados FERNANDO LIMA FARIAS e MICHAEL XAVIER como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas em fase de Execução.

Em razão da pena aplicada, expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor dos réus.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento do valor apreendido, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se seu nome no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.
P.R.I.C.

São Paulo, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA